

1500673-84.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HEBER GUALBERTO MENDONCA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... pelo TJPR) e/ou atenuantes, pois, a despeito de reconhecer o tráfico, negou ter partido com a droga do Paraná, na tentativa de desvencilhar-se do aumento da pena referente ao tráfico interestadual, o que demonstra estar-se diante de mera confissão qualificada, ou seja, reconhece a prática do tráfico, mas invoca, ao mesmo tempo, circunstância a afastar a causa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

4ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500673-84.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500673-84.2022.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO MARCOS CARVALHO DOS SANTOS e outro

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEBER GUALBERTO MENDONCA

I - Do Relatório

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de ANTONIO MARCOS CARVALHO DOS SANTOS, qualificado às fls. 4 e 50 e GILLEADY GADYEL GUIRAU DE SOUZA, qualificado às fls. 5 e 53, dando-os como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, em tese, no dia 1º de maio de 2022, por volta das 2h30, na Rodovia Assis Chateaubriand (SP 425), altura dos Kms 276 e 266, zona rural, nos limites do Município de Barbosa-SP, nesta Comarca de Penápolis, agindo em unidade de propósitos, transportavam drogas para venda e entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em 2,68 Kg (dois quilos e seiscentos e oitenta gramas) de "maconha".

Segundo o MP, apurou-se que os denunciados, residentes na cidade de Paranavaí-PR, uniram-se para o desenvolvimento do tráfico de drogas e transportavam entorpecente do Estado do Paraná, utilizando-se do veículo GM Astra, placa EXF9494, conduzido

por ANTONIO MARCOS e levando como passageiro o codenunciado GILLEADY.

Conforme a denúncia, durante patrulhamento de rotina, a polícia rodoviária notou que o veículo ocupado pelos denunciados estava em alta velocidade, no Km 266, no município de Barbosa, nesta comarca. A ordem de parada foi desobedecida e houve perseguição ao veículo dos denunciados.

De acordo com a acusação, em meio à fuga, o passageiro do veículo, GILLEADY, dispensou na rodovia estadual três tablets da droga entre os Km 267 e 268. Com apoio policial, os denunciados foram abordados no Km 266 da citada rodovia.

Narra a denúncia que, após, com o apoio de outras viaturas policiais, logrou-se êxito na localização e apreensão dos tablets (forma de "tijolos") dispensados na rodovia durante a fuga. Foram apreendidos telefones celulares na posse dos acusados, sendo um da marca Motorola na posse de ANTONIO e 02 (dois) telefones da marca Samsung em poder de GILLEADY. O veículo utilizado também foi apreendido.

Por fim, consoante a acusação, a perícia constatou que se tratava de 2,68 Kg (dois quilos e sessenta e oito gramas) de maconha o entorpecente transportado.

Notificado (fl. 145), o réu Antonio Marcos apresentou defesa preliminar (fls. 125/126).

Notificado (fl. 147), o réu Gilleady apresentou defesa prévia (fls. 221/222).

A denúncia foi recebida no dia 29.7.2022 (fls. 224/228).

Durante a instrução, ouviram-se 2 (duas) testemunhas comuns (fls. 334/335), sendo os réus interrogados ao final (fls. 332 e 333).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos termos da denúncia (fls. 330/331).

A defesa do réu Antonio Marcos Carvalho dos Santos, em memoriais, requereu a absolvição do acusado (fls. 336/338).

A defesa do réu Gilleady Gadyel Guirau de Souza, em memoriais, requereu a absolvição do acusado (fls. 339/341).

II - Da Fundamentação

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou plenamente comprovada pelo: i) auto de prisão em flagrante (fl. 1); ii) boletim de ocorrência (fls. 6/8); iii) auto de exibição e apreensão (fls. 13/14); iv) laudo de constatação provisória (fls. 22/24); v) laudo pericial definitivo para maconha (fls. 109/111); e vi) auto de destruição da droga (fls. 116/117).

Resta saber se a autoria delitiva foi comprovada pela prova oral.

A Testemunha/C PM Vinicius Alves Norte disse que estavam em patrulhamento, quando o tal veículo Astra passou em alta velocidade. Deram sinal de parada, mas o veículo evadiu-se. Pediram apoio, pelo que o veículo foi abordado em Barbosa e, no meio do caminho, jogaram 3 tijolos pela janela do passageiro - deu para ver que se tratava de tijolo, de cor verde. Depois de abordado o veículo, voltaram no ponto em que arremessados e encontraram os tijolos, no pé da placa. Os demais foram encontrados na sequência. Um deles alegou que não sabia da droga e o outro falou que a droga era dele. O passageiro disse que a droga era dele e o condutor disse que receberia um dinheiro apenas para transportar o veículo e que fugiu porque ficou nervoso. Salvo engano, eles teriam saído do Paraná e iriam para São Jose do Rio Preto. A

abordagem aconteceu por volta das 2h30 e o acompanharam o veículo de perto, sem distanciamento. O motorista negou qualquer conhecimento sobre a droga. Quanto ao passageiro do veículo, ele só disse que pegou a droga no Paraná e iria para São José do Rio Preto e não lembra dele ter falado que tinha parentes em Rio Preto (fl. 334).

A Testemunha/C PM Júnior Trindade Gastaldi confirmou as informações de seu colega, acrescentando que estavam de patrulhamento entre Penápolis e Barbosa. O condutor fez menção de parar o veículo em algumas vezes, mas não o fez. Com uso de lanternas, deu para ver que arremessaram tijolos de cor verde. Só depois conseguiram aborda-los, com ajuda da equipe de Barbosa, tendo retornado e encontrado primeiro um tijolo de maconha e, mais adiante, outros 2. O passageiro disse que a droga era dele e que o motorista estava lá porque Gilleady o contratou para fazer o transporte do carro para Rio Preto, onde Gilleady tinha parente, que também seria o destino final da droga. Salvo engano, saíram do Paraná. Não lembra se os dois pararam em Prudente – se chegaram a mencionar isso – mas estavam vindo do Paraná. Segundo o motorista, ele não parou porque estava nervoso e o passageiro também pediu para ele prosseguir.

Em seu interrogatório ANTONIO MARCOS CARVALHO DOS SANTOS disse que o outro réu lhe procurou perguntando quanto cobraria para levá-lo à cidade de Rio Preto, na cidade da mãe dele, tendo então saído de Paranavaí. Pararam num posto, na cidade de Prudente, para comer algo. Ficaram lá uns 20 minutos. Gilleady disse que ia conversar com um amigo dele, enquanto ele foi ao banheiro e foi comer. Acha que ele conversou com o amigo antes de entrar na conveniência. Não notou se ele estava com alguma mochila ou embrulho. O carro era do Gilleady e a chave ficou com ele. Ele não veio dirigindo porque não é habilitado. Saíram do posto e continuaram a rota, quando então foram parados em Barbosa. Antes, deram sinal de luz mas não sabia se era um carro para ultrapassar ou se era a polícia, pelo que não parou. O giroflex ainda não estava ligado. Depois ligaram o giroflex e ele disse ser a polícia, quando então Gilleady começou a dispensar os pacotes embaixo do banco (não lembra se pegou do banco de trás ou debaixo do banco) e dizia “não para não”. Continuou em linha reta e, quando viu a outra viatura na frente, deu seta e parou. Gilleady disse que tinha jogado droga mas não especificou a quantidade. Em nenhum momento Gilleady lhe disse que tinha droga, nem sentiu cheiro de entorpecente. Passaram por 3 fiscalizações no Estado do Paraná, mas sem que tenham sido parados. Era mototaxista, pelo que recebia um salário líquido de R\$ 1.300,00. Saíram de sua casa por volta das 20h00, tendo Gilleady dirigido o carro até a frente de sua casa. Disse não conhecer o caminho e que só dirigiu porque Gilleady não tinha habilitação. Foi seguindo o GPS. O depoente ia dormir lá e voltaria no outro dia. Não levou roupa, indo só com a roupa do corpo.

Em seu interrogatório GILLEADY GADYEL GUIRAU DE SOUZA disse que recebeu proposta para pegar droga em Presidente Prudente e levar a São José do Rio Preto. Como não tinha CNH, foi até Larissa, uma amiga da sua esposa, e pediu seu carro para ver sua mãe em São José do Rio Preto. Foi com o carro até a casa do Antônio e pegaria R\$ 200,00 para levá-lo até Rio Preto. Conhece-o porque ele é mototaxista que presta serviço para sua esposa. Vieram e, quando chegaram em Prudente, pararam no Posto Prudentão e ligou para uma pessoa, um conhecido seu de quando morou em Presidente Prudente, que o encontrou no banheiro. Ele comentou com o tal rapaz que iria ver sua mãe, em São José do Rio Preto, quando então o sujeito lhe fez a proposta. Pegou os 3 tabletes de maconha e escondeu a droga embaixo do banco. Estavam dentro de uma bolsa preta. Antônio não viu ele guardando essa bolsa preta, até porque ele estava dentro da Conveniência comendo e tomando guaraná. Entrou na conveniência, comeu e chamou Antônio para prosseguir. Passaram pela polícia de Penápolis, que vieram atrás dele, dando sinal de luz, porém Antônio não parou porque era só um sinal de luz. Continuaram e então os PMs ligaram o giroflex, tendo o depoente mandado Antônio prosseguir e tirou a bolsa debaixo do banco, tendo Antônio visto quando ele jogou a droga, questionando-o onde pegou isso. Jogou um tablete por vez e depois

jogou a bolsa. A Polícia os pegou pouco adiante, além da PM também. No carro não encontraram nada e, perguntado o que foi jogado, encontraram a droga, tendo o depoente reconhecido ser dele e que não sabia de nada. Combinou com Antônio que ele voltaria logo em seguida com o carro. Iria ficar uns dias na casa de sua mãe, de ônibus. Não estava trabalhando, mas tinha acabado de combinar um serviço logo após o feriado, como construtor. Não levou mala. Seu contato com Antônio foi tão-somente porque ele prestava serviço de mototáxi para sua esposa.

Pois bem.

O conjunto probatório é conclusivo, apto, pois, a embasar a condenação de ambos os réus.

De antemão, vale destacar que o delito de tráfico de drogas ficou cabalmente demonstrado nos autos, ante a palavra dos policiais rodoviários.

De fato, ambos agentes ouvidos pelo Juízo, confirmaram que faziam patrulhamento, no momento que cruzaram pelo veículo dos acusados e estes não obedeceram à ordem de parada. Disseram que, durante o acompanhamento, foram dispensados do veículo, pelo lado do passageiro, três tabletes de maconha.

Além disso, contaram que, após conseguirem abordar o veículo, o passageiro confessou ter jogado a droga e que fazia o transporte do Estado do Paraná até a cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo.

O testemunho dos policiais merece credibilidade, pois se reveste de idoneidade e credibilidade suficientes a embasar, juntamente com os demais elementos de prova, o decreto condenatório. O simples fato de ser policial não macula a prova oral de parcialidade, a não ser que haja prova em contrário nesse sentido, o que não ocorreu nos presentes autos.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

"Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial". (TJMG. Apelação Criminal nº 1.0349.08.020068-7/001. Relatora Des. MARIA CELESTE PORTO. 5ª Câmara Criminal. Julgado em 27/01/2009).

PROVA - Testemunha - Palavra de policiais quanto aos atos de diligência - Validade - Inexistência, nos autos, de qualquer evidência de má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público - Pedido revisional deferido em parte para reduzir a pena, fixado o regime inicial fechado (Revisão Criminal 99302019068600 - Monte Azul Paulista - Relator Antonio Sérgio Coelho de Oliveira - 16/04/2009 - Voto nº: 7929).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Credibilidade - A só condição de policial não o torna suspeito - Depoimento colhido sob compromisso de dizer a verdade, como de qualquer testemunha, que deve ser examinado dentro de todo o conjunto probatório - Seria estranho o Estado selecionar pessoas para integrarem o quadro da Polícia e depois suspeitar delas quando agem no cumprimento do dever, ainda mais se inexistente interesse dos policiais em prejudicar o acusado - Entendimento - Recursos parcialmente providos (Apelação Criminal 99305025506900 - São Miguel Arcanjo 11ª Câmara de Direito Criminal - Relator José Odorico de Oliveira Passos - 17/09/2008 - Voto nº 16.395).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Eficácia - Depoimentos de policiais, que efetuaram a prisão em flagrante, harmônicos, coerentes e firmes que ratificam os fatos narrados na denúncia e nenhuma razão tinham para incriminar os acusados, sem

motivo plausível ou causa justificável - Credibilidade - Recursos improvidos (Apelação Criminal 11391843000 - Barretos - 11ª Câmara do 6º Grupo as Seção Criminal - Relator Antônio Manssur 30/01/2008 - Voto nº 14.068).

Insta salientar que não ficou demonstrado nos autos motivo algum para que os policiais quisessem incriminar falsamente os acusados, imputando-lhes o delito de tráfico de drogas interestadual, não se mostrando que incriminariam aleatoriamente os réus sem qualquer motivo anterior que justificasse tamanha ilegalidade. São funcionários públicos no exercício de suas funções e depõem em Juízo sob o dever de dizer a verdade.

O réu Antonio Marcos, em Juízo, limitou-se a negar a prática do delito de tráfico de drogas, dizendo que somente conduziu o veículo, sem ter a ciência da droga.

Já o réu Gilleady, em Juízo, confessou ter recebido uma proposta para transportar a droga, porém apenas de Presidente Prudente/SP a São José do Rio Preto/SP. A negativa do conhecimento do réu Antonio Marcos, em relação ao transporte das drogas, não merece acolhimento, pois não se mostra crível que tenha aceitado fazer mero transporte de veículo, saindo do Estado do Paraná e indo para São José do Rio Preto/SP, sem supostamente conhecer o caminho e, ainda, sabendo que se tratava de destino de longa distância, não levar mala alguma, sem contar que, em se tratando de 2,68 Kg (dois quilos e seiscentos e oitenta gramas) de "maconha", divididas em 3 tijolos, o cheiro do entorpecente dentro do carro certamente tornaria o condutor consciente do que estava transportando e, podendo interromper o trajeto, não o fez.

Além disso, o histórico criminal do réu Gilleady mostra seu envolvimento passado com o tráfico, o que corrobora seu consciente envolvimento (de Antônio Marcos) com o crime em tela, juntamente com o outro corréu.

Dessa forma, também não merece crédito a negativa do réu Gilleady em relação ao tráfico interestadual, pois ao dizer que saiu do Estado do Paraná, fez escala em Presidente Prudente/SP para pegar, as drogas e levá-las para São José do Rio Preto/SP, está tentando se livrar da qualificadora correspondente ao transporte de drogas entre os Estados da Federação, vez que os policiais rodoviários confirmaram que o acusado admitiu transportar as drogas do Estado do Paraná até a cidade de São José do Rio Preto/SP - e de fato, não faz sentido que o suposto traficante de Presidente Prudente tivesse contratado alguém do Paraná para transportar a droga até São José do Rio Preto.

Dessa forma, pelas provas colhidas nos autos, ficou cabalmente demonstrado que os réus tinham ciência do transporte da droga, seja pelo depoimento dos policiais e pela confissão do réu Gilleady, que é suficiente para imputar-lhes a responsabilidade penal quanto ao delito de tráfico de drogas interestadual, pois, de qualquer modo, eles confirmaram o itinerário de sua viagem, ou seja, saíram do Estado do Paraná com destino final em São José do Rio Preto/SP.

Passo, assim, à dosimetria das penas.

II.a. Do réu Antonio Marcos Carvalho dos Santos

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP são favoráveis ao réu, pois possui bons antecedentes, razão pela qual fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor.

Na segunda fase, sem agravantes e/ou atenuantes.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do artigo 40, V, da Lei 11.343/2006, pois pelas provas constantes dos autos, o tráfico tinha finalidade o transporte de

maconha entre o Estado do Paraná e São Paulo, pelo que aumento a pena de 1/6, perfazendo 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no menor valor.

Por outro lado, não há a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, pois, embora o réu seja primário, não é caso de beneficiá-lo com o reconhecimento do tráfico privilegiado, porque há que se reconhecer que, ao se dispor a transportar a significativa quantidade de drogas (2,68 Kg de maconha) entre Estados da Federação, com remuneração de R\$ 200,00, deixou entrever que estava envolvido com atividade criminosa organizada, já que ninguém obtém acesso à quantidade que ela dispunha, a não ser por meio de alguma organização criminosa.

Não se trata de negar o redutor em decorrência apenas da quantidade, mas principalmente diante da constatação de que o perfil do acusado não se encaixa na figura do traficante eventual, que surpreendido comercializando algumas poucas porções, a quem o legislador reservou o favor legal.

Ressalte-se, não ser o caso de aplicação do artigo 41 da Lei 11.343/2006, uma vez que o aludido dispositivo prevê que, para ver-se beneficiado pela diminuição, deve o acusado "colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação", sendo que, na hipótese sub judice, o aludido dispositivo legal prevê a causa especial de diminuição de pena da "Delação Premiada", ou seja, hipótese em que o acusado delata eventuais comparsas ou fornecedores da droga que comercializava. Não é o caso dos autos.

Por tais fundamentos, fixo a sua pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no menor valor.

No mais, ressalto que a pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, na redação dada pela Lei nº 11.464/2007.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por entender incabível tal providência. A boa hermenêutica das normas penais determina que, havendo conflito entre normas especiais e gerais, prevalece a primeira. Desse modo, prevendo a Lei Especial o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena, inviável que se aplique regra geral em sentido diverso, permitindo a substituição da pena.

E não há qualquer inconstitucionalidade nesse ponto. O legislador apenas está concretizando a vontade do Poder Constituinte de tratamento mais severo aos delitos equiparados a hediondos. Ademais, as hipóteses de cabimento das penas alternativas estão elencadas em lei ordinária (art. 44 do CP), razão pela qual nada obsta que lei de mesma hierarquia afaste a sua incidência a outros delitos, forte no princípio da especialidade.

O legislador agiu com acerto. Determinou a redução de pena (elevada) ao sentenciado nas hipóteses do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, mas já advertiu que essa diminuição não conduz à aplicação de penas alternativas, pois incompatível com a determinação constitucional de tratamento mais severo e com os protocolos firmados pela República Federativa de combate ao tráfico ilícito de drogas.

De qualquer forma, as circunstâncias do crime desautorizam a substituição da pena privativa de liberdade (art. 44, III, do CP). É que a venda de entorpecentes, além de demonstrar insensibilidade do traficante com a saúde alheia, é conhecidamente o vetor dos demais delitos. Aquele que delibera praticá-lo demonstra total desprezo

com o bem estar social e uma ganância desmedida, circunstâncias que não se coadunam com a sanção em meio aberto, a qual apenas fomentaria e facilitaria o seu contato com usuários e dependentes; sem contar a odiosa sensação de impunidade que se transmitiria à sociedade, deturpando a finalidade de prevenção geral da sanção penal.

Com efeito, se as penas alternativas estão vedadas, com muito mais razão a suspensão condicional da pena, já que o espírito da lei foi trazer um tratamento mais rigoroso aos crimes de tráfico de drogas, em consonância com a vontade do Poder Constituinte.

Por fim, quanto à superveniência do art. 387, § 2º, do CPP, destaque-se que, mesmo considerado o tempo de prisão provisória, não é caso de alterar-se o regime prisional, haja vista que ele foi fixado levando-se em conta não só a quantidade da pena, mas todo o contexto fático em que consumado o crime (quantidade, remuneração pelo transporte, tráfico interestadual).

II.b. Do réu Gilleady Gadyel Guirau de Souza

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP são desfavoráveis ao réu, já que possui maus antecedentes (0009689-31.2012.8.16.0130 - fls. 204/205), razão pela qual fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, no importe de 1/6, ou seja, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no menor valor.

Na segunda fase, sem agravantes (a condenação mencionada pelo MP, de fls. 211/212, foi reformada pelo TJPR) e/ou atenuantes, pois, a despeito de reconhecer o tráfico, negou ter partido com a droga do Paraná, na tentativa de desvencilhar-se do aumento da pena referente ao tráfico interestadual, o que demonstra estar-se diante de mera confissão qualificada, ou seja, reconhece a prática do tráfico, mas invoca, ao mesmo tempo, circunstância a afastar a causa de aumento de pena.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do artigo 40, V, da Lei 11.343/2006, pois pelas provas constantes dos autos, o tráfico tinha finalidade o transporte de maconha entre o Estado do Paraná e São Paulo, pelo que aumento a pena de 1/6, perfazendo 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no menor valor.

Por outro lado, não há causa de diminuição, pois o réu não é primário, não é caso de beneficiá-lo com o reconhecimento do tráfico privilegiado, porque, ao se dispor a transportar a significativa quantidade de drogas que foi apreendida, deixou entrever que estava envolvido com a traficância, já que ninguém obtém acesso à quantidade que ele dispunha, a não ser por meio de alguma organização criminosa. Não se trata de negar o redutor em decorrência apenas da quantidade, mas principalmente diante da constatação de que o perfil do acusado não se encaixa na figura do traficante eventual, que surpreendido comercializando algumas poucas porções, a quem o legislador reservou o favor legal.

Ademais, quando da prisão, o réu revelou aos policiais que adquiriu droga no Estado do Paraná para levá-la a São José do Rio Preto/SP, circunstância indicativa de que vinha se dedicando às atividades criminosas.

Ressalte-se, não ser o caso de aplicação do artigo 41 da Lei 11.343/2006, uma vez que o aludido dispositivo prevê que, para ver-se beneficiado pela diminuição, deve o acusado "colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação", sendo que, na hipótese sub judice, o aludido dispositivo legal prevê a causa especial de diminuição de pena da "Delação Premiada", ou seja, hipótese em que o acusado delata eventuais comparsas ou fornecedores da droga que comercializava. Não é o caso dos

autos.

Por tais fundamentos, fixo a sua pena definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no menor valor.

No mais, ressalto que a pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, na redação dada pela Lei nº 11.464/2007.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por entender incabível tal providência. A boa hermenêutica das normas penais determina que, havendo conflito entre normas especiais e gerais, prevalece a primeira. Desse modo, prevendo a Lei Especial o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena, inviável que se aplique regra geral em sentido diverso, permitindo a substituição da pena.

E não há qualquer inconstitucionalidade nesse ponto. O legislador apenas está concretizando a vontade do Poder Constituinte de tratamento mais severo aos delitos equiparados a hediondos. Ademais, as hipóteses de cabimento das penas alternativas estão elencadas em lei ordinária (art. 44 do CP), razão pela qual nada obsta que lei de mesma hierarquia afaste a sua incidência a outros delitos, forte no princípio da especialidade.

O legislador agiu com acerto. Determinou a redução de pena (elevada) ao sentenciado nas hipóteses do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, mas já advertiu que essa diminuição não conduz à aplicação de penas alternativas, pois incompatível com a determinação constitucional de tratamento mais severo e com os protocolos firmados pela República Federativa de combate ao tráfico ilícito de drogas.

De qualquer forma, as circunstâncias do crime desautorizam a substituição da pena privativa de liberdade (art. 44, III, do CP). É que a venda de entorpecentes, além de demonstrar insensibilidade do traficante com a saúde alheia, é conhecidamente o vetor dos demais delitos. Aquele que delibera praticá-lo demonstra total desprezo com o bem estar social e uma ganância desmedida, circunstâncias que não se coadunam com a sanção em meio aberto, a qual apenas fomentaria e facilitaria o seu contato com usuários e dependentes; sem contar a odiosa sensação de impunidade que se transmitiria à sociedade, deturpando a finalidade de prevenção geral da sanção penal.

Com efeito, se as penas alternativas estão vedadas, com muito mais razão a suspensão condicional da pena, já que o espírito da lei foi trazer um tratamento mais rigoroso aos crimes de tráfico de drogas, em consonância com a vontade do Poder Constituinte.

III – Do Dispositivo

Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para:

III.a. CONDENAR o réu Antonio Marcos Carvalho dos Santos, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, devendo cumprir a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no menor valor.

III.b. CONDENAR o réu Gilleady Gadyel Guirau de Souza, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, devendo cumprir a pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no

menor valor.

Nego o direito aos réus de apelarem em liberdade, porque se trata de crime que coloca em risco a população de pequenas e pacatas cidades. Com efeito, os réus responderam ao processo presos e nessa condição devem permanecer, agora sob novo título calcado em cognição exauriente, devendo, aqui, lembrar que Gilleady já foi condenado definitivamente por tráfico/associação e Antônio, por sua vez, está sendo condenado por tráfico de grande monta (quantidade de droga e interestadual). Assim, em salvaguarda da ordem pública e aplicação da lei penal, devem continuar no cárcere pelos prazos legais. Recomendo-os na prisão em que se encontram, observando-se o regime prisional imposto.

Deve a droga apreendida ser destruída se ainda não foi, ficando, ainda, decretado o perdimento dos celulares periciados às fls. 153/180, dada a não prova de suas origens lícitas.

Custas ex lege.

Honorários advocatícios à Patrona nomeada, nos termos do Convênio OAB/DP (fl. 76).

P.I.C.

Penápolis, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA